

1500554-93.2020.8.26.0571

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Alfredo Gehring Cardoso Falchi Fonseca

Comarca: Itapetininga

Foro: Foro de Itapetininga

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 26/01/2022

... ser afastada a causa de aumento do tráfico, pois não ficou evidenciado se estavam juntos para fins de atividade ilícita de tráfico ou se apenas conversaram, pois são parentes, de forma que qualquer conclusão diversa implica em responsabilidade penal objetiva, não admitida. Ainda na terceira fase, de rigor a aplicação do redutor do tráfico, nos termos do art. 33, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itapetininga

Foro de Itapetininga

2ª Vara Criminal

Avenida Peixoto Gomide, centro, Itapetininga - SP - cep 18200-160

TERMO DE AUDIÊNCIA - VIDEOCONFERÊNCIA

Processo nº:

1500554-93.2020.8.26.0571 - Controle 2020/000864

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JEAN PIRES BRAGA

Data da Audiência:

26/01/2022

Iniciados os trabalhos por videoconferência, com concordância das partes, verificou-se a presença do Exmo. Sr. Dr. Alfredo Gehring Cardoso Falchi Fonseca, MM. Juiz de Direito da Segunda Vara Criminal de Itapetininga, dos representantes do Ministério Público e da Defensoria Pública. Ausente o acusado Jean Pires Braga, tendo sido decretada sua revelia às fls. 161. Antes de serem inquiridas as testemunhas foram devidamente advertidas acerca da incomunicabilidade. Foram ouvidas as testemunhas Tania Rafaela Amaro e Adriano de Salles Afonso arroladas pelas partes. Os depoimentos foram registrados pelo sistema Microsoft Teams. Pelas partes foi dito que não tinham diligências a requerer. Pelo(a) MM(a). Juiz(a) foi dito que: Não havendo mais provas a serem colhidas, declaro encerrada a instrução, determino as partes que passem aos debates. Dada a palavra ao Dr. Promotor de Justiça, foi dito: MM. Juiz, acha-se processado o acusado como incurso no artigo 33 e 35, c.c. artigo 40, inciso VI, todos da Lei de Tóxicos, em face dos fatos detalhadamente narrados na denúncia. Concluída a instrução, a ação penal merece proceder. A materialidade delitiva encontra respaldo no laudo de exame químico-toxicológico acostado aos autos. Autoria e existência delitiva, ao seu turno, vêm comprovadas nos elementos colhidos sob o crivo do contraditório. Ouvidos nos autos, tanto em juízo como em solo judicial, os policiais militares narraram toda dinâmica dos fatos, afirmando que realizavam patrulhamento quando receberam notícia do tráfico praticado por dois indivíduos numa casa da Vila Nova Itapetininga, inclusive com fotografias ilustrando atividade típica do comércio espúrio por eles praticado. Dessa forma, rumaram até o local informado, e tão logo ingressaram na via já se depararam com o acusado e o adolescente infrator, que ao avistarem a viatura tentaram se evadir ingressando no imóvel. Ao se aproximarem, observaram que o acusado dispensou algo, sendo certo que na abordagem apreenderam dinheiro com

o adolescente, e o objeto dispensado pelo agente tratava-se de porções de crack. Como a denúncia dava conta de que havia droga em um terreno contíguo à casa, localizaram e apreenderam as demais porções de entorpecentes, pelo que efetuarão a prisão do acusado e apreensão do adolescente. As palavras dos policiais revestem-se de imensurável valor probatório, uma vez que isentas e desprovidas de qualquer intenção de prejudicar o agente. Demais disso, não há nenhum elemento capaz de indicar uma suposta suspeição do agente público; ao contrário, revela de forma absolutamente convincente toda dinâmica da diligência que resultou na prisão em flagrante. Dessa forma, patente a conduta atribuída ao réu, sendo certo que a quantidade da droga, dividida em porções e acondicionada em unidades embaladas e prontas para a mercancia clandestina, indica claramente que se destinavam, sim, ao tráfico, tanto que estava a realizar o comércio em prévia associação com o adolescente infrator, apreendido à mesma ocasião, também em situação flagrancial. Vale acrescentar, em adição, que o acusado, após ganhar liberdade, não mais compareceu aos atos do processo, comportamento que não se adequa a quem pretende invocar condição de inocência. Portanto, demonstradas autoria e materialidade, pugna a Justiça Pública pela procedência da ação penal, condenando-se o acusado nos exatos termos da denúncia, pelos delitos de tráfico e associação em concurso material, aderindo-se a causa de aumento de envolver adolescente. Não se apresenta cabível a aplicação do redutor ao tráfico, devendo, na mesma toada, ser fixado regime inicial fechado para o débito da sanção carcerária. Dada a palavra ao Dr. Defensor, foi dito: MM. Juiz: Segundo consta na denúncia, o dia 15 de abril de 2020, nesta cidade e comarca, o réu trazia consigo drogas que supostamente seriam destinadas ao tráfico. Em razão disso foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06. O acusado foi notificado e apresentou sua defesa preliminar. A audiência de instrução, debates e julgamento foi realizada em 26 de janeiro de 2022, oportunidade em que foram ouvidas as testemunhas arroladas na denúncia. O réu foi notificado e citado, porém, por não ter sido mais localizado, foi intimado por edital, não compareceu ao ato processual e teve a revelia decretada. Os policiais narraram que estavam em patrulhamento receberam denúncias com fotos contra o Acusado. Foram até o local e avistaram o réu com outro indivíduo. Ao verem a guarnição, tentaram entrar na residência, porém, foram abordados. Teria sido dispensado pelo Acusado Jean dez porções de crack e em um terreno teria sido localizado mais trinta e seis porções de crack. Informaram que o terreno era localizado próximo ao local onde estava o Acusado. É o relatório.

INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. A) EM RELAÇÃO À ASSOCIAÇÃO. Verifica-se que não há elementos concretos para a condenação dos acusados pelo crime previsto no artigo 35, caput, da Lei 11.343/2006, diante da fragilidade das provas produzidas. Destaca-se que este delito somente é punido na modalidade dolosa, consistindo o dolo na deliberada intenção do agente de integrar a associação, assumindo tarefa específica, vinculada aos demais integrantes. Sobre o dolo do delito de associação não basta: "(...) a existência de simples dolo de agir conjuntamente, em concurso, na prática de um ou mais crimes. É imprescindível a verificação de dolo distinto, específico: o dolo de associar-se de forma estável". (MARCÃO, Renato. Tóxicos. 8ª Ed. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 252). A ligação com a associação deve ser comprovada por provas objetivas que permitam identificar a missão do acusado dentro do grupo, além de prova específica a respeito da reunião estável e permanente dos agentes (animus associativo). De igual maneira decidiu o STJ: "esse crime [associação para o tráfico] reclama concurso de duas ou mais pessoas de forma estável ou permanente, ligadas pelo animus associativo dos agentes, não se confundindo com a simples coautoria." (HC 149.330-SP, Rel. Min. Nilson Naves, julgado em 6/4/2010). No caso em tela, para além da negativa dos Acusados, a acusação não trouxe elementos que demonstrassem estabilidade e permanência entre os Acusados. Com efeito, não há provas sobre função e há quanto tempo estariam associados, elementos que não imprescindíveis para a comprovação da acusação. Desse modo, resta dúvida que favorece os acusados e, como se sabe, o Direito Penal exige a convicção plena, de maneira que a dúvida, menor que seja, milita em favor do réu, como determina o art. 5, LVII, da CF. Requer-se, portanto, a absolvição, nos termos supracitados. B) EM RELAÇÃO AO TRÁFICO. A versão apresentada pelas testemunhas

acusatórias não é suficiente para demonstrar além de qualquer dúvida razoável que o Acusado estivesse envolvido na prática do crime de tráfico de drogas.

Primeiramente, veja-se que não há indícios suficientes de que o acusado estava praticando o crime de tráfico de drogas, sendo certo que sua versão não foi infirmada pelo restante da prova coligida. Vale ressaltar que o Acusado não foi visualizado em atividade típica de traficância, não trazia dinheiro consigo e não fazia contato com nenhuma outra pessoa (a não ser com o adolescente João Victor). Por outro lado, deve ser ressaltado que com o Acusado havia apenas dez porções de crack e nenhum valor em dinheiro, o que não permite afirmar se as drogas eram de fato para venda ou se, por exemplo, destinavam-se ao consumo, registrando-se que o réu se declarou usuário de entorpecentes (fls. 34). Em relação às demais porções de drogas, foram achadas em um terreno, em local conhecido pela venda de drogas e sem que os policiais tenham visualizado o Acusado entrando ou saindo do referido local, sendo absolutamente impossível lhe atribuir a propriedade da droga ali encontrada. Assim, pelo conjunto probatório não há como saber, sem qualquer margem de dúvidas, se as drogas em posse do Acusado de fato se destinavam à venda ou se havia acabado de adquirir para o próprio consumo. E, de outro lado, não há como atribuir ao Acusado as drogas encontradas no terreno baldio, já que o Réu não foi visto naquele local. Assim, requer a improcedência da ação penal, nos termos do art. 386, VII do CPP e, subsidiariamente, a desclassificação do crime para a conduta descrita no art. 28, caput, da lei de Drogas. Subsidiariamente, na hipótese de condenação, em respeito ao princípio da eventualidade, passa-se à análise da dosimetria da pena a ser imposta ao acusado. Na primeira fase, pleiteia-se a fixação da pena-base no mínimo legal, ante a ausência de requisitos capazes de exasperá-la, nos termos do art. 59 do Código Penal. Muito embora o artigo 42 da Lei de Drogas estabeleça como critério para a dosagem da pena a quantidade e a variedade de entorpecentes apreendidos, é impossível a aplicação de tal norma, na medida em que é difícil avaliar qual quantidade e quais variedades de drogas seriam suficientes para justificar a aplicação da causa de diminuição abaixo do máximo estabelecido em lei. Assim, a inexistência de tal parâmetro faz com que a aplicação de pena seja feita de maneira completamente arbitrária. Na segunda fase, não incidem agravantes, haja vista a primariedade do acusado. Ainda, incide a atenuante da idade do réu, que tinha apenas 18 anos na data dos fatos. Na terceira fase, deve ser afastada a causa de aumento do tráfico, pois não ficou evidenciado se estavam juntos para fins de atividade ilícita de tráfico ou se apenas conversaram, pois são parentes, de forma que qualquer conclusão diversa implica em responsabilidade penal objetiva, não admitida. Ainda na terceira fase, de rigor a aplicação do redutor do tráfico, nos termos do art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/06. Vejamos: Veja-se que não ficou comprovado nos autos que se dedique a práticas criminosas ou que integre organização criminosa, preenchendo

então, todos os requisitos do redutor. Aqui, deve ser observada a regra de tratamento que emana da presunção do estado de inocência, não podendo se admitir que processos ainda em tramitação sejam utilizados para presumir-se a dedicação do Réu em atividades ilícitas. Com efeito, o fato de o Acusado responder a outro processo não o impede de receber o redutor do artigo 33, § 4º da Lei de Drogas, com base no princípio da presunção do estado de inocência que somente é afastado com condenação judicial definitiva, nos moldes da mais recente interpretação do E. Supremo Tribunal (HC 187.180/SP. Rel. Min. Gilmar Mendes. Data de julgamento: 19/06/2020). É justamente por essas razões, amparadas em precedentes da E. Suprema Corte, que se requer a aplicação da causa de diminuição prevista no parágrafo 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06. Quanto ao regime inicial, nos termos do artigo 33 do Código Penal, requer seja fixado o regime aberto para cumprimento da pena. Isso porque, a fixação de regime fechado como decorrência automática do disposto no artigo 2º da Lei n. 8.072/90 contraria o princípio da individualização da pena, previsto no artigo 5º, XLVI, da Constituição Federal. Cumpre ressaltar que o Plenário do C. Supremo Tribunal Federal, durante o julgamento do Habeas Corpus nº 111.840, em sessão realizada no dia 27 de junho de 2012, declarou incidentalmente a inconstitucionalidade do parágrafo 1º do artigo 2º da Lei n. 8.072/90, com redação dada pela Lei n. 11.464/07, o qual prevê que a pena por crime hediondo (inclusive

tráfico de drogas) será cumprida, inicialmente, em regime fechado. De tal forma, ante as peculiaridades do caso em tela, claro está que não há razão para a determinação de regime fechado, ainda que não se aplique o redutor em seu grau máximo. Não obstante, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do HC 596.603/SP assentou o entendimento de que condenados por tráfico privilegiado possuem direito subjetivo ao cumprimento da pena em regime inicialmente aberto. Cabível, ainda, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, haja vista que o artigo 44 foi considerado inconstitucional pelo E. STF (HC n. 97.256/RS), o que motivou a expedição da Resolução n. 05, de 2012, do Senado Federal, suspendendo, nos termos do art. 52, X, da CF a expressão “vedada a conversão em penas restritivas de direitos do art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/06”. No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do HC 596.603/SP assentou o entendimento de que condenados por tráfico privilegiado possuem direito subjetivo à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Diante do exposto, requer sejam acolhidas as teses defensivas, nos termos da fundamentação supra. Por fim, requer seja concedido o direito de recorrer em liberdade, bem como a gratuidade de justiça, com isenção de custas processuais, por se tratar o acusado de pessoa hipossuficiente nos termos da lei. Na sequência, pelo MM. Juiz foi proferida a seguinte sentença: Vistos. JEAN PIRES BRAGA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 33, “caput”, e no art. 35, “caput”, ambos c.c. o art. 40, inciso VI, todos da Lei nº. 11.343/2006, na forma do art. 69, do Código Penal. De acordo com a denúncia, em dia, horário e lugar incertos, nesta Cidade e Comarca, agindo em concurso e com identidade de propósitos, associou-se ao adolescente João Vitor da Silva Santos, para o fim de praticarem, reiteradamente, o crime de tráfico ilícito de drogas. Em 15 de abril de 2020, por volta das 14 h e 30 min, na Rua Valdomiro Vaz da Rocha, n. 90, Vila Serafim, nesta Cidade e Comarca de Itapetininga, o Réu, agindo em concurso e com identidade de propósitos com o mencionado adolescente, enquanto colocavam em prática as atividades para as quais a associação delituosa fora constituída, guardava e mantinha em depósito, para fins de tráfico, quarenta e seis porções de “crack”, com peso de 9,95 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Notificado por edital, fls. 88, o Acusado apresentou defesa preliminar, fls. 101/102. A denúncia foi recebida, fls. 103, e o Réu citado por edital, fls. 108. Jean Pires, citado por edital, não compareceu em Juízo e não constituiu defensor, deste modo o feito foi suspenso, com fundamento no art. 366, do CPP, fls. 118. Após, foi o Réu citado pessoalmente, fls. 133. Durante a instrução, foram colhidos os depoimentos das testemunhas arroladas pelas partes. Foi decretada a revelia do Réu. Em alegações finais o Dr. Promotor de Justiça pugnou a condenação nos exatos termos da inicial; por outro lado, a Dra. Defensora insistiu na absolvição e, de forma subsidiária, na aplicação de benefícios. É o relatório. I – FUNDAMENTO. A pretensão punitiva estatal é parcialmente procedente. Análise a prova coligida. Presente a materialidade do delito. Às fls. 16/17 foi juntado o Auto de Exibição e Apreensão no qual consta: R\$ 139,00; diversas embalagens plásticas; um telefone celular, marca Motorola, cor preto e quarenta e seis pedras de “crack”, com peso de 10,86 gramas. Às fls. 21/23 e fls. 25/26 foram juntadas fotografias. O Laudo Pericial de Exame Definitivo n. 124.809/2020 no qual apontou: “Do resultado. Utilizando-se metodologias adequadas para análise do referido material, foi detectada a presença da substância Cocaína, constante na lista F1: Lista das Substâncias Entorpecentes - Lista das Substâncias de uso Proscrito no Brasil da portaria SVS/MS 344/1998 e atualizações posteriores”. Tânia Rafaela Amaro e Adriano de Salles Afonso, policiais militares, disseram que estavam em patrulhamento e tinham recebido denúncia da prática de tráfico de entorpecentes por dois rapazes, cujas fotos foram fornecidas; o local já era conhecido pelo comércio ilícito; em diligências foram ao ponto indicado e, ao entrarem na rua, viram os dois rapazes, que tentaram ingressar na casa, quando o Réu dispensou algo; fizeram a abordagem e, com o adolescente, encontraram dinheiro e, nas proximidades, os policiais localizaram as porções dispensadas pelo Acusado; no terreno ao lado, com o auxílio de cães farejadores, houve a apreensão de mais drogas, embaladas da mesma forma que as dispensadas pelo Acusado; no interior da residência os policiais localizaram plásticos usados para

embalar drogas. Confrontando-se a prova coligida, verifica-se que a parcial procedência é medida que se impõe, pois os policiais viram o momento em que o Acusado dispensou 10 porções de "crack", que estavam embaladas em um saco plástico, portanto pequena quantidade e compatível com a destinação própria, havia poucas unidades e não foi presenciado qualquer ato de fornecimento. Tratando-se de usuário de entorpecentes, óbvio que as drogas lhe pertenciam, notadamente porque as dispensou, todavia, ausentes informações de venda, a conclusão é que as drogas eram destinadas ao uso pelo Acusado. Em relação às outras porções encontradas com o auxílio de um cão farejador, não podem ser imputadas ao Acusado, pois nem mesmo os policiais o viram dispensar essa droga ou até mesmo reiteradamente se deslocar ao terreno para atender usuários. Por fim, apesar da apreensão de embalagens e da denúncia anônima, à míngua de outros elementos, tais provas são insuficientes para a condenação por tráfico de entorpecentes. Em síntese, em virtude de todas essas circunstâncias, não se autoriza a prolação de decreto condenatório por infração ao artigo 33 da Lei de Drogas e mister é a desclassificação da conduta imputada ao Réu para a tipificada no artigo 28, da Lei n.º 11.343/06, o que faço com fulcro no artigo 383 do Código de Processo Penal. Por óbvio, com a desclassificação, a absolvição em relação ao delito de associação é medida que se impõe, pois, além de não estar demonstrado o vínculo estável entre o Réu e o adolescente, sequer se demonstrou a finalidade de venda drogas. II – DA DOSIMETRIA DA PENA. (Art. 59, inc. II, do Código Penal). Fixada a responsabilidade do Acusado, passo à dosimetria da pena. ART. 28, DA LEI 11.343/2006: Atento às circunstâncias previstas no artigo 59 do Código Penal e aos critérios contidos no artigo 42 da Lei n.º 11.343/06 aplico ao Réu a pena de advertência. III – DECIDO. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A DENÚNCIA e o faço para DESCLASSIFICAR a imputação contida na denúncia e o faço para condenar, JEAN PIRES BRAGA, qualificado nos autos, a pena de ADVERTÊNCIA, dando-o como incurso no artigo 28, caput, da Lei n.º 11.343/06. Absolvo-o da acusação de incidir no art. 35, c.c. o art. 40, inciso VI, todos da Lei n.º 11.343/2006, com fundamento no art. 386, inc. VII, do CPP. Dá-se a pena por cumprida. Defiro a liberação do dinheiro. Sem condenação nas custas. Sentença publicada em audiência. Cumpra-se. A presente audiência foi realizada excepcionalmente por meio virtual, diante da Pandemia do COVID-19. O Termo de Audiência ficará disponível no sistema SAJ, ficando os presentes intimados do prazo de 5 (cinco) dias para interposição do recurso da sentença, dispensada a assinatura das partes, por se tratar de processo digital - sistema SAJ (Artigo 1.269 das NSCGJ). Nada Mais. Itapetininga, 26 de janeiro de 2022. Eu, (Marina Alice Correa de Almeida), Escrevente Técnico Judiciário digitei.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA